

1501966-15.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501966-15.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501966-15.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MARCIO VIEIRA DE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MARCIO VIEIRA DE CAMARGO, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 307 do Código Penal, artigos 16, §1º, IV e 12, ambos da Lei 10.826/03, os dois últimos na forma do artigo 70 do Código Penal porque no dia 26 de agosto de 2021, às 13h10, na Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1452, Jardim Silveira, nesta cidade e comarca: a. Atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio; b. Possuía arma de fogo de numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar; c. Possuía 23 munições calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 27 de agosto de 2021 (fls. 50/51).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fl. 9), assim como o laudo de exame da arma de fogo (fls. 82/85) e o laudo de exame das munições (fls. 86/89).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 101/104). Em 11 de fevereiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 105/106).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a).

O Ministério Público apresentou alegações finais ao término da audiência (fls. 126/127), ao passo que a defesa o fez por escrito (fls. 135/144).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) MARCIO VIEIRA DE CAMARGO foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 26 de agosto de 2021, às 13h10, na Avenida Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1452, Jardim Silveira, nesta cidade e comarca: a. Atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio; b. Possuía arma de fogo de numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar; c. Possuía 23 munições calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento suspeitaram da atitude do réu, abordaram-no e sob a posse dele nada encontraram, mas ao ser indagado sobre sua identidade, ele disse chamar-se "Lucas", mas denotou nervosismo e não apresentou documento, depois disse que se chamava Márcio e indicou sua residência, para onde todos se dirigiram a fim de que fosse verificado o documento de identidade do réu. A tia do denunciado estava no imóvel e franqueou o ingresso, no interior foram encontrados 1 revólver calibre 32 sob o guarda-roupa e 23 munições calibre 22 numa caixa sobre um dos móveis, além do documento de identidade, que permitiu constatar que o réu estava foragido.

Concluída a instrução processual, entendo que o Ministério Público conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia.

A materialidade do delito foi apenas parcialmente comprovada. O laudo de fls. 82/85 atesta que a arma de fogo apreendida não estava apta para efetuar disparos, pois os mecanismos de percussão e disparo estavam avariados. Quanto às munições, por outro lado, a materialidade foi comprovada e o laudo de fls. 86/89 documenta a prestabilidade dos cartuchos apreendidos.

A autoria também é certa, ante a prova produzida nas duas fases da persecução. Com efeito, em solo policial e em juízo as testemunhas Anderson e Joaquim declararam que são policiais militares e na data do fato, durante o patrulhamento, suspeitaram do comportamento do réu. Inicialmente ele disse que se chamava Lucas, mas então ficou ainda mais nervoso, mas disse que o nome verdadeiro era Márcio. Não portava documento, mas indicou a residência, próxima dali. Uma familiar do réu estava na casa e autorizou o ingresso dos depoentes, em buscas pelo documento pessoal do réu encontraram uma arma de fogo e munições em quantidade. Localizado o documento dele, em pesquisas junto ao sistema próprio verificaram que estava foragido de um estabelecimento prisional.

O próprio réu admitiu que estava mesmo sem documento de identificação consigo e que, em razão disso, os policiais o conduziram à referida residência para que o documento fosse obtido e verificado. No local, sua tia autorizou o ingresso deles para que esse documento fosse encontrado.

A tia do réu prestou depoimento em juízo e confirmou essa versão dos fatos, no que lhe cabia falar, isto é, que realmente autorizou o ingresso dos policiais na sua casa para que eles pegassem o documento de seu sobrinho, o réu.

A defesa técnica do réu se insurge contra tudo isso alegando que não há prova de que o réu tenha se identificado com nome diverso do seu, o que caracteriza o crime de falsa identidade, e que as buscas realizadas no seu cômodo são ilegais porque injustificadas.

De fato, o consentimento do réu e da tia do réu para o ingresso não parecem ter se dirigido às buscas no cômodo. Se o objetivo dos policiais era identificar civilmente o réu, o que me parece estar em consonância com a Lei Federal n. 12.037/2009, natural que, quando encontrassem a cédula de identidade dele ou outro documento desse jaez simplesmente parassem de diligenciar no local. Em tese, portanto, a continuidade das diligências é mesmo estranha, o que poderia inquirir de nulidade a prova obtida:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.

1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1).

2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da cessação da prática delitiva.

2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da sociedade.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado.

4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de

estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc.

5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos - diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.

5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial - meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada - legitimar a entrada em residência ou local de abrigo.

6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio.

6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento "deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ('consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (*totality of circumstances*).

6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito.

6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (*North Carolina v. Butler* (1979) 441 U.S. 369, 373; *People v. Ramirez* (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; *U.S. v. Castillo* (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (*Haley v. Ohio* (1947) 332 U.S. 596, 601; *People v. Andersen* (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579).

6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa - ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção -, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, "necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/T0).

6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal - analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial - ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º".

7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.

7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça compete, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares.

8.1. As decisões do Poder Judiciário - mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição - servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para "enriquecer o estoque das regras jurídicas" (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos.

8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (*Weeks v. United States*, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada ("such proceeding would be to affirm by judicial

decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action").

8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.

9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública.

10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor.

11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal."

(STJ - 6ª T., HC n. 598.051-SP - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 02.03.2021 - Dje 15.03.2021, grifo não original)

Ao que compreendo da exposição dos policiais militares, contudo, não houve propriamente buscas por outras coisas que não a cédula de identidade do réu, nem, encontrada a identidade, prosseguiram eles fazendo buscas aleatórias no imóvel dele ("fishing expedition"), a violar a sua privacidade domiciliar. Isso seria desvio de finalidade e, por conseguinte, invalidaria a prova.

O que ocorreu, na verdade, foi um encontro fortuito da arma e das munições, o que também é reconhecido pela jurisprudência como sendo algo que não invalida a prova. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO VERIFICADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Ao contrário das alegações defensivas, o mandado judicial de busca e apreensão apresentou fundamentação idônea, destinando-se à coleta de provas relacionadas a atividades ilícitas de facção criminosa integrada por aproximadamente dez indivíduos, dentre os quais, o ora agravante.

2. Embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução.

3. Agravo regimental não provido."

(STJ – 5a T., AgRg no HC 703948 / SC – rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 08.03.2022 – DJe 11.03.2022)

Passo à dosagem da pena.

Para o crime do artigo 307 do Código Penal está prevista pena-base de detenção, de três meses a um ano, ou multa. Já para o crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/06 está prevista pena-base de detenção, de 1 a 3 anos, e multa.

Considerando que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, como será adiante exposto, não é adequada ao caso a incidência da pena isolada de multa para o crime do artigo 307 do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, a pena-base deve ser ficada acima do mínimo legal, em razão do mau antecedente do réu, que foi condenado nos autos 0006172-19.2003, que tramitaram perante a Vara Criminal da Comarca de Itapevi, trânsito em julgado operado em 05/11/2008 (fls. 93/94).

No que diz respeito ao crime de posse das munições, como são várias, a pena-base deve ser elevada também por conta da maior reprovabilidade da conduta do réu.

Por conta disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 3 meses e 15 dias de detenção para o crime de falsa identidade e em 2 anos de detenção para o crime de posse ilegal de munição.

Na segunda fase de aplicação da pena, está presente a agravante da reincidência, pois o réu foi condenado definitivamente em 04/09/2015, nos autos 0064834-08.2013, que tramitaram perante a 15ª Vara Criminal da Capital (fl. 92).

De outro lado, deve ser observada a confissão do réu quanto à prática do crime de falsa identidade. Elevaria a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, mas em virtude da atenuante concomitantemente aceita, passo a elevar a pena em 1/5.

Para o crime de posse ilegal de munições a pena deve ser simplesmente elevada em 1/3, pois não houve confissão do réu.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 4 meses e 6 dias de detenção para o crime de falsa identidade e em 2 anos e 8 meses de detenção para o crime de posse ilegal de munição.

A pena de multa do segundo crime citado acima deve seguir o mesmo parâmetro da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 26 dias-multa. Estando o réu preso e sem comprovação de renda, o valor da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Em razão da reincidência e maus antecedentes, a pena de detenção deve ser iniciada no regime semiaberto. Preso desde 26 de agosto de 2021, ele tem direito à detração para que seja fixado o regime aberto. Na ausência de casa do albergado, ele deverá cumprir a pena, oportunamente, em regime de prisão domiciliar.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) MARCIO VIEIRA DE CAMARGO como incurso nos artigos 307 do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/03, ao cumprimento de 3 (três) anos e 6 (seis) dias de detenção, no regime inicial aberto, em regime de prisão domiciliar, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e, ainda, para absolver o réu da acusação de prática do crime do artigo 16, §1º, IV da Lei 10.826/03, com fundamento no artigo 386, II do Código de Processo Penal.

Dado o regime inicial de cumprimento de pena, permito que o réu recorra em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA